

الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية
بجامعة نواكشوط

فعالية الرقابة القضائية للقاضي الإداري من خلال استخدام سلطة الأمر

The effectiveness of judicial oversight by administrative judges through the use of their authority to issue orders

ملخص:

لا شك أن فاعلية رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة تعد أحد المرتكزات المؤدية إلى إعلاء مبدأ الشرعية وأحد العناصر الأساسية في تحقيق دولة القانون ، لذلك كانت استجابة المشرع لمطالبة الفقه بإقرار سلطة الأمر للقاضي الإداري أحد العناصر الأساسية في تحقيق هذه الفاعلية ، خاصة وأن المنهج التقليدي القائم على أساس المنع المفروض على القاضي الإداري كان يقف حجرة عثرة أمام الفاعلية والتي ترتبط في أغلب الأحوال بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها ، وهذا يشكل في الواقع أقوى نقاط الضعف للقضاء الإداري ، ويعتبر عيبا خطيرا يمس هيئته ويقضي على جانب كبير من الآمال المعقودة عليه من جانب الأفراد، خاصة وأن هذا الامتناع عن التنفيذ لا يتعلق بنوع معين من الأحكام بل يمكن أن يلحق كل حكم يصدره القاضي الإداري.

لذلك كان الاعتراف بهذه السلطة للقاضي في البداية مدخل وهدف أساسي لتحقيق هذه الفاعلية والقضاء على هذا التعسف من جانب الإدارة ، خاصة بعد العجز الذي سجل على الوسائل الأخرى كدعوى الإلغاء والتعويض وصعوبة تطبيق الدعوى الجزائية عمليا .

ثم ما لبث المشرع خاصة في فرنسا أن تدخل بقانون القضاء الاستعجالي سنة 2000 الذي وسع من سلطات هذا القضاء ، وكان بحق صورة مميزة في تقرير الحماية القضائية وبالتالي لم تبقى سلطة إصدار الأوامر كمظهر فقط لترتيب النتائج المترتبة عن الحكم الصادر في الموضوع ، بل تعداها لتشمل الإجراءات ، ثم أن استحداث هذه السلطة للقاضي الإداري كان له بالغ الأثر على عملية بناء الرقابة القضائية ، ويظهر ذلك خاصة من حيث النطاق الذي أتيحت للقاضي استخدام هذه السلطة فيه ، ثم الآثار التي يمكن أن تنعكس على المنظومة القانونية والقضائية من جراء استخدام هذه السلطة والتي هي في الحقيقة تعد أحد عناصر الوظيفة القضائية .

فالتماطل في تنفيذ الأحكام يخلق الشك لدى المتقاضين من جدوى اللجوء إلى القضاء لمنازعة الأشخاص المعنوية العامة ، ويشكل رفض تنفيذ الأحكام القضائية تمردا كافيا لشل العمل القضائي.

Article Summary

Undoubtedly, the effectiveness of administrative judicial oversight of administrative actions is a cornerstone of upholding the principle of legality and a fundamental element in establishing the rule of law. Therefore, the legislature's

response to the legal scholars' demand to grant the administrative judge the power of enforcement was a key element in achieving this effectiveness. This is especially true given that the traditional approach, based on the restrictions imposed on the administrative judge, hindered this effectiveness, which is often linked to the enforcement of court rulings issued against the administration. This constitutes one of the most significant weaknesses of the administrative judiciary, a serious flaw that undermines its prestige and diminishes the public's expectations. This refusal to enforce rulings is not limited to a specific type of judgment but can affect any ruling issued by the administrative judge.

Article Summary

Undoubtedly, the effectiveness of administrative judicial oversight of administrative actions is a cornerstone of upholding the principle of legality and a fundamental element in establishing the rule of law. Therefore, the legislature's response to the legal scholars' demand to grant the administrative judge the power of enforcement was a key element in achieving this effectiveness. This is especially true given that the traditional approach, based on the restrictions imposed on the administrative judge, hindered this effectiveness, which is often linked to the enforcement of court rulings issued against the administration. This constitutes one of the most significant weaknesses of the administrative judiciary, a serious flaw that undermines its prestige and diminishes the public's expectations. This refusal to enforce rulings is not limited to a specific type of judgment but can affect any ruling issued by the administrative judge

المقدمة:

لا شك أن فاعلية رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة تعد أحد المرتكزات المؤدية إلى إعلاء مبدأ الشرعية وأحد العناصر الأساسية في تحقيق دولة القانون ، لذلك كانت استجابة المشرع لمطالبة الفقه بإقرار سلطة الأمر للقاضي الإداري أحد العناصر الأساسية في تحقيق هذه الفاعلية ، خاصة وأن المنهج التقليدي القائم على أساس المنع المفروض على القاضي الإداري كان يقف حجرة عثرة أمام الفاعلية والتي ترتبط في أغلب الأحوال بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضدها ، وهذا يشكل في الواقع أقوى نقاط الضعف للقضاء الإداري ، ويعتبر عيباً خطيراً يمس هيئته ويقضي على جانب كبير من الآمال المعقودة عليه من جانب الأفراد(353)، خاصة وأن هذا الامتناع عن التنفيذ لا يتعلق بنوع معين من الأحكام بل يمكن أن يلحق كل حكم يصدره القاضي الإداري.

353-حمدي علي عمر، المرجع السابق ، ص 23.
- الحبيب العطشان ، المرجع السابق ، ص 156.

لذلك كان الاعتراف بهذه السلطة للقاضي في البداية مدخل وهدف أساسي لتحقيق هذه الفاعلية والقضاء على هذا التعسف من جانب الإدارة ، خاصة بعد العجز الذي سجل على الوسائل الأخرى كدعوى الإلغاء والتعويض وصعوبة تطبيق الدعوى الجزائية عمليا .

ثم ما لبث المشرع خاصة في فرنسا أن تدخل بقانون القضاء الاستعجالي سنة 2000 الذي وسع من سلطات هذا القضاء ، وكان بحق صورة مميزة في تقرير الحماية القضائية وبالتالي لم تبقى سلطة إصدار الأوامر كمظهر فقط لترتيب النتائج المترتبة عن الحكم الصادر في الموضوع ، بل تعداها لتشمل الإجراءات ، ثم أن استحداث هذه السلطة للقاضي الإداري كان له بالغ الأثر على عملية بناء الرقابة القضائية ، ويظهر ذلك خاصة من حيث النطاق الذي أتيحت للقاضي استخدام هذه السلطة فيه ، ثم الآثار التي يمكن أن تنعكس على المنظومة القانونية والقضائية من جراء استخدام هذه السلطة والتي هي في الحقيقة تعد أحد عناصر الوظيفة القضائية .

فالتماطل في تنفيذ الأحكام يخلق الشك لدى المتقاضين من جدوى اللجوء إلى القضاء لمنازعة الأشخاص المعنوية العامة ، ويشكل رفض تنفيذ الأحكام القضائية تمردا كافيا لشل العمل القضائي¹.

ورغم أن المشرع والقضاء أخذ بعدد الحلول والجزاءات للتخفيف من حدة المشكلة والقضاء عليها إلا أن ذلك لم يكن بالشكل الكافي الذي يردع الإدارة للكف عن المماطلة والمراوغة ، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين من جهة ويلحق الأذى بالنظام القانوني ذاته في الدولة من جهة أخرى ، لكون تلك التصرفات هي مخالفة للقانون وبالتالي كان الاعتراف بهذه السلطة في الأساس للمساهمة إلى جانب الوسائل الأخرى في حل المشكلة (المطلب الأول) . إلا أن رغبة المشرع في زيادة فاعلية الحماية القضائية دفعت به بعد ذلك إلى تمكين القضاء المستعجل الذي هو أحد العناصر الأساسية في مجال الحماية القضائية، لإمكانية استخدام هذه السلطة في بعض المجالات، كالأوامر المتعلقة بحماية الحريات الأساسية أو ما يعرف بقضاء الحريات والأوامر في مجال العقود والصفقات أو ما يعرف في فرنسا قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي وهو ما كان له بالغ الأثر في تقوية الرقابة القضائية وشكل قفزة نوعية تنبئ عن مستقبل واعد للرقابة القضائية في هذا المجال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تدخل القاضي باستخدام سلطة الأمر لتحقيق تنفيذ الأحكام

من المسلم به أن واجب الإدارة أن تلتزم بتنفيذ القرارات القضائية الحائزة على حجية الشيء المقضي فيه في وقت مناسب وبمجرد صدورها وإعلانها إليها ، لأن احترامها للقانون الذي هو فوق الجميع يسمو عليها هي أيضا ، وإن تجاوزت هذه المدة المعقولة أو تباطأت أو امتنعت عن ذلك دون سند من قانون فإنها ترتكب مخالف لحجية الشيء المقضي به تعادل مخالفة القانون 354، يجوز للمحكوم له المطالبة بإلغاء هذا التصرف لأنه يعد بمثابة قرار سلمي ويتقرر له الحق في طلب التعويض عنه.

فأى قاعدة قانونية أو تنظيم قضائي يفقد سبب وجوده إن لم يكن فعالاً، فالقضاء يعني وضع نهاية للنزاع وإلا فإنه يصبح لا شيء، كما أن التنفيذ هو سبب وجود الأحكام القضائية وإلا فلا شيء سبب تصدر إن لم تكن لتنفيذ³⁵⁵.

ورغم أنه من الصعب تحديد نسبة الإخلال بالتنفيذ لغياب المعطيات الدقيقة على ذلك إلا أنها ظاهرة موجودة ومعروفة لا يستثنى منها أي بلد، لكنها تزيد وتنقص من مجتمع إلى آخر بحسب ما هو متاح للمتقاضين من آليات ووسائل في النظام القانوني تقلل من وجودها، إلا أن التعرض ومحاولة استقصاء هذه النسب ليس له الأهمية مثل التعرض لصور وأسباب (أولاً) ثم تحديد مدى نجاح العلاج الذي قرره التشريعات في التخفيف من حدتها إلى أبعد حد من خلال الجزاء المقرر لذلك (ثانياً).

أولاً: صور وأسباب الإخلال بتنفيذ أحكام القضاء الإداري

النية السيئة للإدارة حين لا تريد تنفيذ الحكم تأخذ عدة أشكال تبدأ من التباطؤ أو التراخي في التنفيذ، مروراً بإساءة التنفيذ أو تنفيذ الحكم تنفيذاً ناقصاً على غير ما قصده الحكم وانتهاء بالرفض الكلي والصريح وهو أشد أنواع الانحراف في استخدام السلطة³⁵⁶. وتتعدد الأسباب التي تتذرع به الإدارة وترجع إليها التأخير في تنفيذ قرارات وأحكام القضاء أو الامتناع من تنفيذها، ففي بعض الحالات تتذرع بوجود صعوبات مادية، وفي حالات أخرى ترجع الإدارة إخلالها إلى اعتبارات مستمدة من مصلحة المرفق العام وحسن سيره أو إلى اعتبارات الأمن و النظام العام.

1- صور الإخلال بالتنفيذ:

يأخذ الخطأ في مجال مخالفة الإدارة لحجية الشيء المقضي به صوار متعددة تتفق كلها مع الأحوال المختلفة للخطأ المرفقي ولا شك أن استخدام الإدارة أي وسيلة من وسائل الامتناع عن تنفيذ الأحكام تتوقف على مدى الآثار المترتبة على الحكم بالنسبة للإدارة، فإذا كانت آثار تنفيذه خطيرة عليها فإن رفض تنفيذ الحكم في هذه الحالة قد يكون سافراً أما إذا كانت خطورة الآثار أقل درجة فإن صور الامتناع عن التنفيذ قد تنحصر في التراخي أو التنفيذ الناقص أو المبتور³⁵⁷.

أ. التباطؤ أو التراخي في تنفيذ الحكم أو القرار: حيث يشكل التأخير في التنفيذ التجاوز الأكثر شيوعاً من قبل الإدارة عندما لا تقبل هزيمتها بشكل صريح، ففي غالب الأحوال يشكو المتقاضين من التأخير أكثر مما يشكون من الرفض الصريح³⁵⁸. وشكلت الطعون المتعلقة بالتأخير نتيجة الصعوبات

355- حسني عبد الواحد، المرجع السابق، ص 392.

356- وهذه الصور المختلفة للامتناع لا تخرج عما استقر عليه فقهاء القانون العام بالنسبة لصور الخطأ المرفقي والتي حصروها في ثالث صور: - المرفق لم يؤدي الخدمة، المرفق أدى الخدمة بطريقة سيئة، المرفق أدى الخدمة لكن ببطء شديد.

357- للتفصيل أكثر أنظر: أحمد الصايغ، إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمغرب ن دراسة تطبيقية، الطبعة الأولى، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، 2009، ص 114 وما بعدها.

358- ذهب جيلس الشيوخ الفرنسي في تقرير له حول مدى تطبيق أحكام العدالة الإدارية والمقدم من طرف السيناتور HAENEL المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية 11 جوان 1992 إلى الإشارة إلى أن نسبة عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري تشكل 77.0.

القانونية أو ضعف الاعتمادات المالية حسب الإحصائيات أكثر المطالبات أمام مجلس الدولة الفرنسي³⁵⁹، وفي هذه الصورة لا تمتنع الإدارة عن التنفيذ صراحة ولكنها تتأخرون تباطاً في القيام به دون مبرر معقول ، بحيث يفهم من هذا التأخير غير المقبول والذي تجاوزت به الإدارة حدود المهلة أن الإدارة لا تريد القيام به ، ومثل هذا السلوك وان كان للوهلة الأولى لا يعني عدم التنفيذ الصريح فهو مع ذلك له نفس النتيجة بالنسبة للمتقاضين³⁶⁰.

وبموجب هذا الأسلوب تتعلل الإدارة بمجموعة من الحيل كغموض مضمون وأثار الحكم أو تدعي أنها تجد نفسها في وضعية لا تستطيع أن تحدد بدقة ما يجب عليها القيام به تنفيذاً لهذا الحكم القضائي ، أو تدعي أن التنفيذ غير ممكن لأن النزاع ما زال محل استئناف أمام مجلس الدولة مع أنها تعلم أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ أو تتذرع بانعدام صفتها وسلطتها في التنفيذ لخضوعها لسلطة وصائية أو انعدام الميازنية... الخ . لكنها في أحيان كثيرة تستعمل هذه الطريقة كوسيلة تضعف بها حجية الشيء المقضي به مع الوقت ، وتثبیط عزيمة المتقاضي من جهة أخرى.

ب. التنفيذ الناقص أو الجزئي : في هذه الصورة تقوم الإدارة بتنفيذ الحكم القضائي لكنها لا ترتب عليه جميع الآثار القانونية التي يتطلبها منطوقهما يجعل تنفيذه قاصراً ومبتوراً كأن يقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظف وتقوم الإدارة بتنفيذ هذا القرار بإلغاء إعادة الموظف إلى وظيفة أخرى أو وظيفة ذات اختصاصات أضعف وأقل مرتبة مع أن القرار واضح يفترض إعادة المحكوم له إلى ذات الوظيفة السابقة³⁶¹، أو حين تقوم الجامعة بتنفيذ الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قراراتها برفض قبول الطالب أو تحويلهم يصدر رئيس الجامعة قرارات بقبولهم ولكن في العام الدراسي التالي. وقد يقترن تنفيذها الناقص لهذا الحكم باستصدار المعني بالأمر لأكثر من حكم بالإلغاء والتعويض كما أنها قد تنفذ حكم الإلغاء وتمتنع عن تنفيذ الحكم المتعلق بالتعويض³⁶².

إن تصرف كهذا يشكل إهدار لقيمة الحكم ويصبح التنفيذ بال معنى لأنها لم تراعي ما جاء في منطوق القرار وما ارتبط به من أسباب جوهرية³⁶³ ، وفي هذا تقول المحكمة الإدارية العليا في مصر أن << مقتضى الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به الذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره ... فإن كان القرار صادراً بالتسريح استتبع إلغاؤه قضائياً

من المائة من عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ويمكن القول أنها تشكل نوعاً من التأخير في التنفيذ بدل رفضه أنظر في ذلك :

Pontier (S), L'exécution des décisions du juge et l'application des injonctions, www.Avodroits-Public.com

359 - FRAISSEIX (P) , Op . Cit . p. 1073

360- بن صالوة شفيقة، المرجع السابق، ص 222 . — أحمد الصايغ، المرجع السابق، ص 115 ، 116 .
361- أشار تقرير سنة 1987 لقسم الدراسات والوثائق بمجلس الدولة لحالة مثل هذه: أن المركز البلدي للنشاط الاجتماعي لمدينة Nantes تظاهر بتنفيذ حكم خاص بأحد أعوانه وفي حقيقة الأمر أوكل إليه مهمة لا تتناسب مع تخصصه مخالفاً بذلك حجية الشيء المقضي به. ومما جاء في التقرير

<<Le centre communal d'action Sociale de Nantes feint d'exécuter un jugement concernant un de Ses agents : en réalité , il lui confie des fonctions ne correspondant pas qualification , en Violation de la chose jugée >>, Rapport précité , E.D.C.E. 1987 P. 199.

أشارت إلى هذا التقرير : بن صالوة شفيقة ، المرجع السابق ، ص 239 .

362- محمد صقلي حسيني ، المرجع السابق ، ص 92 .

363- أنظر تفصيل في الموضوع : عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، المرجع السابق ، ص 541 ، 542 .

بحكم اللزوم إعادة المدعي كما كان في وظيفته التي كان يشغلها عند تسريحه وبمرتبتها ودرجتها كما لو لم يصدر قرار التسريح ... وتنفيذ الحكم يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه ... ومن ثم فال يكفي أن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة الموظف إلى الخدمة وفي مرتبة أدنى ودرجة أقل ، وإلا لكان مؤدى هذا أن الحكم لم ينفذ في حقه تنفيذا كاملا ... وهو جزاء تأديبي مقنع ... >>364

ج. الامتناع الكلي عن تنفيذ الحكم : بموجب هذه الصورة تتخذ الإدارة موقفا سلبيا بحتا إزاء الحكم ، وتتجاهله بصورة مطلقة بأن ترفض القيام بما يفرضه عليها الحكم من التزامات تتمثل في إزالة الآثار المادية والقانونية للقرار الملغى ، وتشكل هذه الحالة على قدر بساطتها خطورة نتيجة ما تتضمنه من مساس صارخ بالأحكام القضائية واستهانة بما لها من قدسية واحترام . وتفشي هذه الظاهرة من شأنه هدم نظام الرقابة القضائية من أساسه وتجريده من كل ميزاته وإضاعة للفائدة منه 365 ، بل تفشي هذه الظاهرة قد يؤدي إلى زوال فكرة العدالة نفسها 366.

وتتجسد هذه الصورة من الرفض الصريح والكلي عادة في القضايا التي تكون الهيئات المحلية طرفا فيها¹ ، إذ أن هذه الهيئات المحلية تفسر خطأ استقلالها ولا ترى نفسها ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضدها ، فضال عن اعتقاد بعض المنتخبين المحليين أن شرعيتهم الديمقراطية تعلو على شرعية القاضي ، فنائب رئيس إحدى البلديات كتب لقسم التقرير بمجلس الدولة الفرنسي أن مجلسه سيد لأن الشعب سيد 367 368 ، مع أنه لا يمكن استبعاد الإدارة المركزية من الوقوف ضد الشيء المقضي به إلا أن ذلك قليل بالمقارنة مع الإدارة المحلية .

د. إعادة إصدار القرار الملغى : قرار الإلغاء لا يصادر حق الإدارة في إعادة إصدار القرار الملغى بعد تجاوز العيوب التي شابهته ، ويظهر هذا بصفة خاصة في تغير الأسانيد القانونية أو المادية التي اعتمدت عليها وقت صدور القرار أو الاستناد إلى وقائع لم يعتمد عليها من قبل . لكن قد تصر الإدارة على الإخلال بالتزاماتها المترتبة على القرار القضائي بقيامها بإعادة إصداره بالمخالفة للشروط والأوضاع التي يتعين مراعاتها عند إعادة إصدار القرار .

وفي هذه المسألة قد تلجأ الإدارة إلى التحايل على التزاماتها بالامتناع عن إصدار القرار الملغى وذلك بالدعاء أن القرار قد صدر بناء على أسباب جديدة تجيز لها ذلك ويتبين عدم صحة هذا الادعاء ، أو أن تصدر القرار الملغى من جديد بدعوى الحفاظ على المصلحة العامة ثم يتبين أنه صدر لذات الغرض الذي من أجله صدر قرار سابق قضى بإلغائه ، فقد تستخدم الإدارة أسلوب آخر في إعادة إصدار القرار الملغى بالاستناد إلى سلطة أخرى لإصداره ، كأن تقوم الإدارة بإصدار قرار نزع الملكية

364-أشار للقرار : حسني سعد عبد الواحد ، المرجع السابق ، 020 ، 023 .

365-عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، المرجع السابق ، ص 540 ، 541.

366-حسني سعد عبد الواحد ، المرجع السابق ، ص 393 .

367-وهو ما عبرت عنه تعليمية صادرة في 03 جوان 6109 مرسلة من طرف الوزير الداخلية للولاية في فرنسا وتتعلق بتنفيذ قرارات العدالة من طرف الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ، حيث أشارت هذه التعليمية إلى أن معظم حالات رفض أو التأخر في التنفيذ للأحكام ناتجة عن هذه الهيئات المحلية وفي هذه التعليمية جاء حث الولاية على التدخل لدى هذه الهيئات لحثها على احترام هذه الأحكام . ذكر هذه التعليمية وما جاء فيها

368-بن صاولة شفيقة ، المرجع السابق ، ص 233 .

لعقار سبق الحكم بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء عليه ، أو أن تقوم بإلغاء الوظيفة التي يشغلها موظف معين سبق الحكم بإلغاء قرار فصله 369.

2- أسباب الإدارة في الإخلال بالتنفيذ:

حين تواجه الإدارة حكما قضائيا نكون أمام ثالث احتمالات 370:

الاحتمال الأول : أن يكون الحكم صادرا ضدها سواء كان عن جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري في إطار القضاء الكامل 371 .

الاحتمال الثاني : قد يكون حكما صادرا بإلغاء قرار لتجاوز السلطة .

الاحتمال الثالث تكون ثمة دعوى مرفوعة من طرف شخص ثالث يطلب المساعدة للتنفيذ

الجبري لحكم صادر ضد شخص آخر إذا كانت الصيغة التنفيذية تسمح بذلك .

وفي هذه الحالات الثالث قد تخل الإدارة بتنفيذه باستخدام الأساليب السابق ، رغم أن الواجب عليها الامتنال لهذا الحكم مهما كانت طبيعة النزاع ، ومستندة إلى مجموعة من الأسباب التي تبررها تصرفها ، وهنا يبرز دور القاضي في تقدير الموقف بدقة شديدة و النظري في مصداقية اعتقادات الإدارة ، فان كان هناك مصبوغ قانوني أو واقعي يقدر الموقف وفقا لهذا الوضع ، أما إذا ظهر أنها أسباب للتهرب من التنفيذ عد ذلك إخلال به يوجب مسئوليتها ، وهذه الأسباب التي تتحجج بها الإدارة تظهر قد تكون ظاهرة أو خفية وتظهر كالتالي 372 :

أ. الإخلال بالتنفيذ حماية للنظام العام : الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثالث (أمن، صحة ، سكينه عامة) هو غاية سامية يسعى النظام القانوني في الدولة إلى الحفاظ عليها، بل ما وجد إلا لتحقيقها ، وفي هذه الحالة يجوز للإدارة إرجاء التنفيذ للحكم لحين زوال الأسباب التي تجعله متعارضا مع النظام العام.

واستنادا إلى هذه الوضعية برر مجلس الدولة رفض الامتنال لحجية الشيء المقضي به في قضية "Couitéas" المعروفة والتي قضى فيها جلس الدولة بمشروعية امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم القضاء نظار لما يؤدي له من تهديد خطير، وأعطى الحق للإدارة في عدم المساهمة في تنفيذه 373.

وقد استلهم المشرع المصري هذا الاجتهاد وضمه في نص المادة 324 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية السابق الذي جاء فيه صراحة >>>...عندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال ب النظام العام إلى درجة الخطورة يمكن للوالي وبطلب مسبب أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة أشهر<< ، وإذا كانت هذه الظروف تعطي للإدارة الحق في تجاهل الحكم القضائي لسمو الصالح

369- عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، المرجع السابق ، ص 549 -. عبد الغاني بسيوني ، المرجع السابق ، ص 651 .

370- بن صاولة شفيقة ، المرجع السابق ، ص 166 ، 167 .

371- إذا كانت دعوى التعويض ضد الأشخاص العامة من اختصاص القضاء الإداري استنادا إلى المعيار العضوي المقرر بموجب المادة (800) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، فان هناك استثناءات يمكن أن تكون الدعوى مرفوعة على الإدارة أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض كما حددته المادة (802) من ذات القانون، كدعوى المسؤولية الناتجة عن أضرار أحدثتها مركبة تابعة للدولة أو أحد الأشخاص العامة ، الدعوى المتعلقة بمخالفات الطرق.

372- أنظر تفصيل ذلك : أحمد الصايغ ، المرجع السابق ، ص 120 وما بعدها .

373- Long.M et autres ... Les grands arrêts... Op .Cit .pp.053 et s .

العام على المصلحة الخاصة ، فإنه يتعين على الإدارة فحص كل حالة على حدة وتكون الإدارة مقيدة برفض التنفيذ استناداً إلى هذه الحالة بالشروط التالية:

- لا يجوز للإدارة رفض التنفيذ إلا إذا كان ذلك مبرره الحفاظ على النظام العام
- رقابة القاضي لحقيقة الظروف التي أدت إلى رفض التنفيذ .. للمضروور الحق في التعويض ، فال يجوز أن يتحمل العبء لوحده .

ب. الإخلال بالتنفيذ حماية للمصلحة العامة : المصلحة العامة عبارة واسعة المدلول غير منضبطة التحديد ومع ذلك فإن الإدارة قد تتذرع بها متخذة من احترامها سبيل تختفي وراءه في عدم تنفيذ الحكم الصادر ضدها كلية أو تنفذه تنفيذاً ناقصاً ومبتوراً ، متجاهلة أن في احترام أحكام القضاء الإداري تحقيق حقيقي لتلك المصلحة ، فالأحكام القضائية نفسها ومنها أحكام الإلغاء على سبيل المثال إنما تقر هذا الإلغاء لتصويب التصرفات الإدارية تحقيقاً للصالح العام³⁷⁴.

فالحكم هو بمثابة الحلقة الأخيرة والنهاية في إطار الجدل القانوني بين الإدارة والمدعي ضدها ومن المفترض أن يكون قد أثبت فيه مسألة تعارض الحكم مع المصلحة العامة ، وان القضاء حين أصدره قدر أنه لا يمس المصلحة العامة، وما يثار بعد صدوره فالأمر لا يخرج عن كونه وسيلة للتهرب من التنفيذ والمماطلة فيه³⁷⁵.

ذلك أنه إذا كانت الإدارة تسعى إلى غاية مشروعة ومحل اعتبار وهي تحقيق الاحترام الواجب للمصلحة العامة فإنه لا يجوز الوصول إليها بوسائل غير مشروعة وهي الإخلال صراحة أو ضمناً بتنفيذ الأحكام ، ومع ذلك وان كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى إخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطيل سير مرفق عام فإن سلوك الإدارة في تعطيل تنفيذ الحكم يكون مشروعاً حيث تكون الإدارة أمام حالة ضرورة، إلا أن هذه الضرورة يجب أن تقدر بقدرها وال يجب أن يكون هذا هو أسلوبها اتجاه الأحكام بصفة عامة التي لا تروقها .

ج. الإخلال بالتنفيذ نتيجة الصعوبات المادية والقانونية: قد تلجأ الإدارة عندما لا تريد التنفيذ أو تراخي فيه إلى التحجج بوجود صعوبات تحول دون إتمامه وتتمثل هذه الصعوبات في :

- عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ : وهذه صعوبة واقعية تثيرها الإدارة متخذة منها سبباً للامتناع عن التنفيذ ، لأن عدم توافر هذه الأموال أحياناً يشكل عائقاً يحول دون تحقيق مضمون الحكم³⁷⁶. على أن عدم مسئولية الإدارة في هذه الحالة تفرض أن تكون الصعوبة المادية لتنفيذ الحكم حقيقية وتصل إلى حد الاستحالة ، حيث أنه لا تكليف بمستحيل مع ضرورة توافر حسن النية لدى الإدارة ، بمعنى أن لا تكون هي التي أوجدت الصعوبة لاتخاذها مبرراً لاحقاً للامتناع عن التنفيذ حال صدور الحكم ضدها ، حين تجازف مثال بتعيين أو ترقية أخرى نفس الوظيفة التي يجب أن يعود إليها المحكوم له³⁷⁷.

374- حسني سعد عبد الواحد، المرجع السابق، ص 425 . - أحمد الصايغ، المرجع السابق، ص 120 ، 121.

375- عبد المنعم عبد العزيز خليفة ، المرجع السابق ، ص 36 .

376- صالح عبد العليم ، المرجع السابق ، 356 .

377- حسني سعد عبد الواحد ، المرجع السابق ، ص 433 .

-غموض منطوق الحكم: الإدارة ملزمة قانونا بتنفيذ الشيء المقضي به واستخلاص نتائجه ، غير أن هذا الواجب الذي يقع على عاتق الإدارة قد تتدرب الإدارة بعدم تحقيق مضمونه استنادا إلى أنه مشوب بغموض لا يمكنها معه إعمال لأثره ، أو أن هذا العمل لا يدخل في والية القضاء بصفة عامة .

ففي الحالة الأولى يعد وضوح الحكم القضائي وتعليله بطريقة مقنعة أمر لا مناص منه لتسهيل عملية تنفيذه ، ذلك أنه كلما اتصف الحكم بهذا الوضوح والتعليل أصبح عصبانه أمار صعبا من الناحية النفسية³⁷⁸ ، غير أنه أمام غموض الحكم فإن الإدارة إن كانت حسنة النية تنفذه وفقا لما تستنتجه وحدها من منطوقه ، وذلك لأن القاضي الإداري لا يمكنه أن يوجه الإدارة في كل تفاصيل التنفيذ ، ولا يمكن له سوى إعطائها فكرة عامة على الاتجاه الذي يتحدث فيه عن التنفيذ³⁷⁹ .

وفي جميع الأحوال تملك الإدارة العودة إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم لتحديد ما وقع من غموض في منطوق الحكم طبقا لنص المادة 965 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي أحالت إلى المادة 258 منه والتي جاءت الفقرة الأولى منها <<إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته>> ، وفي هذه الحالة لم يبقى للإدارة أن تتدرب بأسباب لتبرير جمودها الذي من شأنه تمديد أجال التنفيذ أو الإخلال به .

ثانيا: جزاء إخلال الإدارة بالتنفيذ

لا تقتصر أهمية الحكم على إصداره إنما كذلك في الجزاء الذي يمكن توقيعه على المدين لحمله على تنفيذه ومدى فاعلية هذا الجزاء في تحقيق ذلك ، خاصة أن الإدارة تتمتع بجملة من الامتيازات تجعلها دائما الطرف الأقوى ، وتدور هذه الجزاءات التي قررها القانون في العناصر التالية :

1- الطعن لتجاوز السلطة:

يعد الطعن لتجاوز السلطة إحدى الطرق القضائية التي قررها القانون للأشخاص لحمل الإدارة على الالتزام بما قرره القضاء ، وهذا في الحالة التي تخالف فيها الإدارة منطوق الحكم ومضمونه سواء بشكل كلي أو جزئي تتراخى في تنفيذه.

لم يكن القضاء في البداية يقبل الطعن في القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكام الإدارية إلا بعد حدوث تطور في مفهوم المخالفة القانونية³⁸⁰ ، ومن هذا التطور أجاز الطعن بالإلغاء في القرارات المخالفة لتنفيذ الأحكام باعتبار مخالفة قوة الشيء المقضي به هي في نفس الوقت مخالفة قانونية. وبعد حكم مجلس الدولة الفرنسي في 08 جويلية 1904 في قضية "Botta" أول حكم أقر فيه جواز الطعن بالإلغاء في القرار المخالف لتنفيذ الحكم ، لأنه شكل كما جاء في ملاحظات مفوض الحكومة "Romieu" مخالفة للقانون مما يجعل قوة الشيء المقضي به إلى جانب القانون واللوائح والعرف والمبادئ العامة للقانون... الخ مصادر للشرعية³⁸¹.

378-الحبيب العطشان ، المرجع السابق ، ص 15 .

379-بن صاولة شفيقة ، المرجع السابق ، 225 .

380-أنظر إبراهيم أوفائدة ، المرجع السابق ، ص 211 .

381 -Long.M et autres , Les grands arrêts ... Op .Cit. p . 00 .

ولم يتردد مجلس الدولة بعد ذلك في قبول الطعن بالإلغاء في القرارات المخالفة للشيء المقضي به ، ولم يبقى عيب مخالفة القانون الوجه الوحيد في هذا الإلغاء ، إذ يمكن الاستناد إلى عيب الانحراف في استعمال السلطة إذا تضمن انتهاكا ومساسا بالأحكام القضائية ، كما لو قامت الإدارة بتعديل أحكام اللوائح المعمول بها لمجرد التمكين من إعادة إصدار قرار سبق للقضاء أن حكم بإلغائه³⁸²، أو إذا ادعت الإدارة أن ثمة أسبابا جديدة أتاحت لها إعادة القرار الملغى، ويتضح للقاضي عدم صحة هذا الادعاء كما حدث في قضية "Dame Lamotte" التي قضى فيها مجلس الدولة بإلغاء قرار صادر عن الوالي بالتنازل على أرض مملوكة للسيدة Lamotte فأصدر الوالي قرار جديدا بالاستيلاء على الأرض فألغى مجلس الدولة قرار الاستيلاء فجاء قرار ثالث من الوالي في 10 أغسطس 1944 استنادا إلى قانون 23 مايو الذي ألغى إمكانية الطعن في قرارات التنازل إلا أن مجلس الدولة ألغى القرار استنادا إلى الانحراف في استعمال السلطة³⁸³.

وقد استعمل القاضي الإداري في مصر هذه المكنة حيث ألغى قرار الوالي الذي منع به استعمال القوة العمومية لتنفيذ الحكم ، باعتباره تجاوزا للسلطة من طرف الإدارة لأنه من غير المعقول الاقتصار في الطعن على القرارات الإدارية المخالفة للقانون على نص تشريعي أو لائحي القرارات الإدارية المخالفة لقوة الشيء المقضي به³⁸⁴.

2- دعوى المسؤولية الإدارية:

إلى جانب حق الشخص في رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار الإدارة الصريح أو الضمني بالامتناع عن التنفيذ ، فإن العمل القضائي قد جرى في مصر أو فرنسا وكثير من النظم على أن حق كل شخص في طلب التعويض عن هذا التصرف من جانب الإدارة ، وأساس الحكم هو الخطأ والضرر³⁸⁵، فالامتناع عن تنفيذ الحكم يترتب مسئوليتها لأنه يعد إجراء خاطئ ينطوي على مخالفة أصل من الأصول القانونية وهو احترام حجية الشيء المقضي به ، ومسئولية الإدارة في تقديم التعويض في هذه الحالة تبنى على أساسين :

إما على أساس الخطأ حيث يعد عدم التنفيذ خروج عن حدود القانون وتحد صارخ للقضاء ورقابته.

كما يمكن أن تقوم مسئوليتها بدون خطأ استنادا إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، وفي هذه الحالة الإدارة لا ترتكب خطأ إنما تمتنع عن تقييم المساعدة في التنفيذ إذا كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى المساس ب النظام العام، وقد تقرر هذا المبدأ في قضية Couitéas السابقة الذكر والتي قرر فيها مجلس الدولة الفرنسي التعويض للمضرور حتى لا يتحمل الضرر لوحده.

وتعد هذه الدعوى ذات أهمية كبيرة نظار لما يتمتع به القاضي الإداري من سلطة في تقدير الضرر وتحديد التعويض الذي يستحقه صاحب الشأن، وتطبق هذه الدعوى على كافة مظاهر وصور

382-عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، المرجع السابق ، ص 559 .

383-C.E Ass , 17 févr. 1950 , Ministre de l'agriculture et dame Lamotte , Rec. , 110 , les grands arrêts ... Op.cit. .p 061 et s .

384-إبراهيم أو فائدة ، المرجع السابق ، ص 065 .

385- أحمد الصايغ ، المرجع السابق ، ص 132 .

مخالفات الإدارة في تنفيذ الأحكام الإدارية ، سواء تعلق الأمر بعدم التنفيذ أو التأخر فيه أو التنفيذ الناقص ، لأن عمل كهذا يعد غير مشروع ويشكل خطأ مرفقي جسيم³⁸⁶، ذلك أن مخالفة قوة الشيء المقضي يعتبر إخلال بقاعدة أساسية تستلزمها ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية ، واحترام قوة الشيء المقضي به تسمو على القاعدة القانونية ذاتها³⁸⁷.

ثم أن تصرف كهذا يعد مساسا بسيادة القانون ، وهو أمر لا يتفق مع أي بلد متحضر كما عبرت عنه محكمة القضاء الإداري في مصر في قرار لها صادر في 19 جوان 1952 >> امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به واجب النفاذ هو مخالفة قانونية صارخة تستوجب مسئولية الحكومة عن التعويضات ، وذلك لأنه لا يليق بحكومة بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية بغير وجه قانوني ، لما يترتب على هذه المخالفة الخطيرة من إشاعة للفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون>>³⁸⁸.

وواكب مجلس الدولة هذا الاتجاه في العديد من قراراته³⁸⁹ ، التي أكد بموجبها مسئولية الدولة عن الإخلال بالتنفيذ في أي صورة من الصور ومن بين تلك القرارات على سبيل المثال قراره الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ 23-04-2001 في قضية القطاع الصحي لبوفاريك ضد (ز، ع) حيث من بين ما جاء في أسبابه >> حيث أن التعويض المحكوم به تبرره القواعد العامة وخاصة المادة 124 من القانون المدني ، كون المستأنف سبب ضرر للمستأنف عليه من جراء الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وهو تصرف خاطئ>> .

غير أن هذه الوسيلة وإن كانت ذات أهمية بالنسبة للمتقاضين في حفظ مصالحه إلا أنها بهذا الشكل يبقى التعويض حل غير مناسب وإقامة ذلك كنظام يعني الاعتراف للإدارة بإمكانية أن تشتري بأموال الجماعة الحق في عدم الامتثال لحجية الشيء المقضي به ، وبعبارة أخرى يكون القاضي قد وافق على الموقف السلبي للإدارة مقابل التعويض وتكون الإدارة قد اشترت بقاء قراراته التعسفية ، وبالتالي تقرير مسؤولية الإدارة بالتعويض في هذا المجال حسب الفقيه "Delvolvé" يسجل عجز القاضي الإداري عن استعمال وسائل السلطة العامة لإجبارها على التنفيذ العيني لحكم الإلغاء ، وهنا يكمن الخطر الجسيم الذي يتمثل في تحول الالتزام بالقيام بعمل ناشئ عن حكم الإلغاء إلى التزام بدفع التعويض ، أي تحريف لوظيفة دور الطعن الموضوعي من وسيلة لحماية المشروعية إلى المطالبة بالتعويض³⁹⁰، وهذا ما جعل هذه الوسيلة منتقدة من عدة جوانب³⁹¹:

- الهدف من رفع دعوى الإلغاء هو إعدام القرار ومحو آثاره ، فتعويض موظف مثال رفضت الإدارة إرجاعه إلى منصبه بعد إلغاء قرار عزله لا يغنيه أبدا عن المنصب.

386- عبد الغاني بسيوني ، المرجع السابق ، ص 653 .

387- أحمد الصايغ ، المرجع السابق ، ص 132 .

388- حسني عبد الواحد ، المرجع السابق ، ص 406 .

389- قرارات غير منشورة ، أشارت إليها : بن صاولة شفيقة ، المرجع السابق ، ص 273 ، 274 .

390- DELVOLVÉ (P) , l'exécution des décisions de justice contre l'administration , E.D.C.E. , 1983-1984 , 111.

أشار إلى هذا الأخير والمرجع : حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص 125 .

391- بن صاولة شفيقة ، المرجع السابق ، ص 125 .

- يتحمل المتقاضي من أجل الحصول على التعويض أعباء ونفقات إضافية قد تزيد عن تلك التي يتحملها في دعوى الإلغاء نفسها.

- الإقرار بدعوى التعويض كبديل عن تنفيذ الحكم القضائي يعني ضياع هيمنة السلطة القضائية وضياع الهيبة والاحترام للقضاء والمساس بممارسته الفعالة له باعتباره إحدى سلطات الدولة، ثم أن جعل التعويض المالي بديلا عن تنفيذ الأحكام يفتح الباب أمام تهاون الإدارة نفسها.

المطلب الثاني: الاعتراف للقضاء الإداري المستعجل بتوجيه الأوامر للإدارة

بعد زوال العقوبات التي كانت تحول دون الاعتراف للقاضي الإداري باستخدام سلطة الأمر في مواجهة الإدارة ، خاصة بعد التحول الإجرائي الذي عرفه النظام القضائي الفرنسي سنة 1980 بصدد قانون الغرامة ، وقانون 1995 الذي وسع من سلطة القاضي الإداري في الأمر وبالتالي إنهاء الاتجاه التقليدي الذي سار عليه القضاء الإداري في فرنسا منذ قيامه .

تلاحقت بعد ذلك التشريعات المختلفة وتدخل المشرع الفرنسي بإصلاح قضائي ساهم في إعادة بناء صرح العدالة الإدارية بموجب قانون 30 يونيو 2000 المتعلق بالإجراءات الاستعجالية والذي يضاهي القانونين السابقين من حيث الأهمية ، إذ تم بموجبه توسيع سلطات قاضي الاستعجال وسن إجراءات استعجالية لكل ميدان من ميادين تدخل الإدارة 392 ، وبذلك كان للمشرع الفرنسي السابق في تنظيم هذه الحماية ، وجاء هذا القانون جامعا لما قننه المشرع وما ابتدعه القضاء وما أعمل فيه الفقه أريه 393، مبتعدا في ذلك عن مرحلة التردد التي أراد من خلال ها جعل نشاط الإدارة بعيدا عن تدخل قاض الأمور المستعجلة 394 ، حيث كان يظهر هذا التطور بالخصوص في الأثر الذي رتبته في مجال الحماية المقررة لحقوق المتقاضين ، من خلال الاعتراف للقاضي الإداري المستعجل في الأمر بكل الإجراءات الضرورية لحماية الحريات الأساسية.

وسار على هذا الطريق المشرع المصري بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية في تبني هذه الصورة ، والتي تعد عنصرا جديدا في هذا القضاء الذي يشكل أحد المعالم الأساسية في بناء الدولة القانونية المرتبطة بحقوق المتقاضين (أولا)، كما عمل المشرع على تقوية سلطات القاضي في الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية وسمح لرفعها بأن يطلب من القاضي استخدام هذه السلطة اللازم الإدارة بضرورة مراعاة قواعد النشر والإشهار عندما يتعلق الأمر بإبرام العقود والصفقات حفاظا

392- بعد صدور قانون 30 جوان 2000 الخاص بالقضاء المستعجل تم استبعاد مصطلح "Sursis exécution" لصالح le référé – Suspension، وبهذا ميز القانون بين ستة أنواع من القضاء المستعجل، وهم : قضاء الوقف -le référé Suspension، القضاء التحفظي le référé Conservatoire وقضاء الحريات ا 6١6٢61أ ٦6٢6٦ ١٦٦ معاينة الاستعجالا "le référé liberté"، قضااء التنسيق الاستعجالي "le constat d'urgence"، قضاء التحقيق الاستعجالي "le référé provision" إضافة لصور خاصة لقضاء الاستعجال . أنظر أكثر تفصيل : Op.Cit. pp. CHAPUS (R) , 1341 et s . –Rouquette (R), petit traité du Procès Administratif ,4em édition , Dalloz , 2010,pp.653 et s.

393-المصطفى الدحاني <<دور القاضي الاستعجالي في حماية الحريات والحقوق>>، مجلة محاكمة، العدد 7-8، 2010، ص 44، 45.

394- الاستعجال في المادة الإدارية> ، مجلة جلس الدولة، العدد 04 ، 2003 ، ص 13.

على المال العام وحقوق المتقاضين ، حيث يملك إصدار أمر للإدارة مع إمكانية ربطه بالغرامة 395 ، وهو الأمر الذي أكدته المشرع الجزائي بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية (ثانياً) .

أولاً : سلطة القاضي الإداري المستعجل في الأمر لحماية الحريات الأساسية:

تعتبر هذه الصورة من الاستعجال أحد المبادئ التي جاءت بها المادة السادسة من القانون الفرنسي رقم 2000 — 597 بتاريخ 30 جوان 2000 والمتعلق بالإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والتي أصبحت المادة 521 الفقرة الثانية من تقنين العدالة الإدارية ، حيث أعطى المشرع للقاضي الإداري المستعجل سلطة توجيه الأوامر للإدارة ، والذي كان محل مطالبة من الفقه من أجل منح الفاعلية اللازمة للقاضي الاستعجال من أجل النطق بالتدابير اللازمة ضد الإدارة في الحالة التي يكون فيها تصرفها يشكل مساساً خطيراً وغير مشروع بإحدى الحريات الأساسية 396.

ذلك أن التسهيلات التي كان يقدمها القضاء لاستعجالي العادي للمتقاضين أدى إلى إفراطهم في الاحتجاج بالاعتداء المادي ، وهو ما دفع المشرع الفرنسي إلى تأسيس قضاء الحريات المستعجل أو ما يعرف باسم قضاء الأوامر كذلك (le référé injonction) كمحاولة للحد من هذا الإفراط 397.

حيث نصت المادة 521 من القانون أعلاه على أنه <<يستطيع قاض الاستعجال أن يأمر بكل الإجراءات الضرورية للحفاظ على الحرية الأساسية في حالة وقوع اعتداء جسيم وواضح وغير مشروع بشكل ظاهر من جانب شخص معنوي عام أو شخص خاص مكلف بإدارة مرفق عام ، وذلك أثناء ممارسة إحدى سلطاته ، ويأمر القاضي المستعجل بهذا الإجراء في خلال 48 ساعة>> ، فهذا النص يظهر التحول الكبير نحو تقوية تدخل القاضي الإداري المستعجل وتوسيع سلطاته في توجيه الأوامر للإدارة لصالح الحماية المقررة لحقوق الأفراد ، وذلك بما يمنحه من ضمانات للمتقاضين وتسهيلات إجرائية تعيد للقاضي الإداري مكانة منافسة للقاضي العادي حامي الحريات 398.

إذ يمكن للقاضي أن يأمر الإدارة بالكف عن التصرف الذي أضرب هذه الحرية أو الامتناع عن إتيان تصرف يمس بها ، وتكمن أهمية هذا النص أنه أعطى لأول مرة للقاضي الإداري في حالة الاستعجال إمكانية استخدام سلطة الأمر قبل أن ينتقل النازع لقاضي الموضوع 399 بحيث مكن القاضي الإداري المستعجل من أن يؤمن بنفسه بواسطة إجراء عاجل الحفاظ على حرية أساسية كما يفعل حين يحكم في الموضوع وخاصة عن طريق دعوى تجاوز السلطة 400.

ومن جهة أخرى سمح للقاضي بالتدخل ولو في غياب قرار إداري وهذا إذا كنا أمام مساس خطير وواضح بحرية أساسية وكان هذا التصرف غير مشروع، أي أن تطبيق هذا النمط من الاستعجال أكثر

1- C.E. ord , ref., 13 décembre , ولل قضية المتعرض لها , 2004 . CHAPUS (R), Op .Cit . pp .1436 ,1437n° 274757 , c/ AL Manar , code pratique , Op .Cit . pp 1134 , 1135 396- CHAPUS (R) ,Op .Cit . p.1320.

397-بن كسيرة شفيقة ، المرجع السابق ، ص 90

398- المرجع نفسه، ص 90 .

399-حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص 166 .

400-Long.M , et autres ... Op .Cit . p. 035 .

اتساعا ، فهو يمتد إلى كل التدابير بمعنى إلى كل السلوكيات الصادرة عن الإدارة ولودون اتخاذ قرار إداري 401.

وقد تأثر المشرع المصري بهذا الإصلاح الذي وقع في القانون الفرنسي وضمنه في المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، إذ نصت هذه المادة على أنه <<يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 أعلاه إذا كانت الظروف الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها ، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات ، يفصل قاض الاستعجال في هذه الحالة في ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تسجيل الطلب>>.

حيث بموجب هذا الطلب انفتح المجال أمام القاضي الاستعجالي بشكل واسع ما دام أن القانون أعطاه سلطة الأمر بكافة الإجراءات الضرورية للمحافظة على حرية أساسية هي في خطر جراء تصرف الإدارة والتي تسمح ليس فقط بفرض التزامات القيام بعمل ولكن أيضا بالتزامات القيام بعمل ، مع اختيار الإجراء المأمور به من طرف القاضي في خلال ثمانية وأربعين ساعة من تسجيل الطلب . وتتمثل الشروط الموضوعية لتطبيق هذه الحالة من الاستعجال والتي تتيح للقاضي التدخل بسلطته في الأمر تو افرثالث شروط هي :

أ. حالة الاستعجال: يعرف الفقه شرط الاستعجال بأنه الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة عليه ، والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولوقصرت مواعيده 402، وهذا الشرط الطبيعي يعد القاسم المشترك لكل الأوامر المستعجلة في المجالات الأخرى التي تفترض وجود حقوق أو مصالح مشروعة يراد حمايتها ، حيث نكون أمام حالة استعجال عندما يكون من طبيعة سلوك الإدارة أن يخلق وضعية ضارة أو خطيرة تتطلب تدخل من القاضي لمنع تفاقمها ، ويصبح على اثر ذلك الضرر هو جوهر الاستعجال وصعب أن يعطى تعريف مستقل عنه ، ويستغرق مفهوم الاستعجال كوجه للضرر في إطار الحماية المستعجلة الأضرار المادية والمالية 403 ، وهذا الشرط هو الذي يبرر سلطة القاضي في التدخل للأمر بالإجراء المطلوب .

ب. وجود مساس بحرية أساسية : يطرح هذا الشرط استفهاما حقيقيا حول هذه الحرية الأساسية ، ذلك أن هذا المفهوم غير المحدد يجعله قابلا للاتساع 404، ولعل أن عدم التحديد فيه فائدة توسعة مفهوم الحرية بما يتلاءم والحماية المستعجلة ، وتبعاً لروح نظامها لا وفقا لتصور محدد من طرف المشرع ، مما قد يؤدي إلى التعارض مع الغاية المقصودة من هذا النظام والتي تستوجب تدخل سريعا درءا لعدوان حال ، خاصة وأن المفهوم العام للحرية يعد من المشاكل المتفاوتة زمنيا، وهذا المفهوم هو الذي راق لمفوض الحكومة السيد "Lamy" بالقول <<...من الأفضل في نطاق الأمور

401-لحسين بن شيخ أث ملويا ، المنتقى في قضاء الاستعجال ، المرجع السابق ، ص 70 ، 71 .

402-المصطفى الدحاني ، المرجع السابق ، ص 45 .

403- المرجع نفسه ، ص 45 ، 46.

404-حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص 168 .

المستعجلة عدم تحديد مفهوم الحرية... >> ، والسيدة سيلفا بقولها >>... إن المشرع لم يشأ أن يحدد مفهوم الحرية الأساسية ليترك ذلك للقضاء ليقدر كل حالة تبعا لظروفها... >> 405.

ويجب أن نلاحظ أن القانون الإداري لا يضع قائمة محددة للحقوق والحريات الأساسية ، وبالرجوع إلى المراجع المتعلقة بالقانون الإداري تحيل مباشرة في هذا المجال إلى الدساتير والاتفاقيات الدولية ، إذ إن الفقه لم يجتمع على قائمة يكون فيه جرد جامع بكل الحقوق والحريات الأساسية ، الأمر الذي يجعل المسألة صعبة نوعا ما أمام القاضي الإداري الذي يعتبر الدرع الواقعي لممارسة الأفراد لحرياتهم الأساسية⁴⁰⁶ ، وذلك لأن القاضي الإداري قاض خاص بمنازعات الإدارة وليس قاض للإدارة ، لذلك تتجسد مهمته في الرقابة وحماية هذه الحقوق والحريات ومنع انتهاكها من جانب الإدارة⁴⁰⁷ .

ومن خلال أحكام مجلس الدولة الفرنسي في مجال الحريات الأساسية المشمولة بسلطته في الأمر بموجب المادة 521 الفقرة الثانية لم يقتصر فهمه على الحريات الفردية ، لكن أيضا الحريات العامة ذات القيمة الدستورية⁴⁰⁸.

أن تكون هناك عدم مشروعية ظاهرة ومساس خطير بحرية أساسية : وهذا الشرط ضروري بصريح القانون ، فقا ض الاستعجال لا يمكنه التدخل لتوجيه الأمر باتخاذ الإجراءات الضرورية إلا إذا كانت الانتهاكات التي قام بها الشخص العام أو من اعتبر القانون منازعته إدارية تشكل مساس خطير وغير مشروع بتلك الحريات ، وتقدير المسألة متروك للقاضي والذي يقدرها حسب كل حالة 409 ، كحالة منع الإقامة على التراب الوطني أو المساس بحرية الحياة العائلية أو رفض قبول اللجوء ... الخ 410 ، وتقدر الجسامة مباشرة بالنسبة للاعتداء الواقع على الحرية الأساسية والذي يدعيه الطاعن 411 ، رغم أن الاعتداء على أي حرية أساسية في الواقع دائما حسب الفقه يشكل مساس جسيم 412 ، مع العلم أنه في بعض الأحيان لضمان السير العادي للمرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة للدولة يمكن تقييد هذه الحقوق دون أن يشكل ذلك مساس بجوهرها. 413

وإذا اجتمعت هذه الشروط فباستطاعة القاضي الأمر بأي تدبير للحفاظ على الحرية الأساسية، مع العلم أن تلك التدابير تكون مؤقتة.

ثانياً: سلطة توجيه الأوامر للإدارة في مجال العقود والصفقات

405- أنظر مع نوع من التفصيل: المصطفى الدحاني، المرجع السابق، ص 51.

406-قاسم العبد عبد القادر <<دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية>>، مجلة إدارة، المجلد 01، سنة 2000 ص 14، 15

407-A Berkane(F) << le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de la démocratie>>, Revue du Conseil D'Etat , n°4, 2003 ,pp. 08 , 10 .

408-CHAPUS (R) ,Op .Cit . pp. 1387 et s .

409-لحسين بن شيخ أث ملو، المنتقى في قضاء الاستعجال، المرجع السابق، ص 74.

CHAPUS (R), Op .Cit . p. 1398 -410

411-حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص 610 .

412۲-3۷6 1'00 | 36لا٤ | 36056۲۹لا6 أ١٥أ 3أ١6:0أ6 3 لا06 1.٤6أ6 ۴00ل3^60أ3ل6 65؛ | 33۲ 65560-6 ج
 << 0۱3؛

413-القاسم العيد عبد القادر، المرجع السابق، ص 60 وما بعدها .

القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية هو إجراء قضائي تحفظي مستعجل خاص، الهدف منه حماية قواعد العلانية والمنافسة بشكل فعال قبل إتمام إبرام الصفقة العمومية، وذلك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة غير مألوفة في الإجراءات القضائية الاستعجالية العامة⁴¹⁴.

والحقيقة أن هذه الصورة كان قد تبناها المشرع الفرنسي في القانون رقم 92-10 المؤرخ في 24 يناير 1992 وأدرجت في تقنين المحاكم الإدارية العادية والاستثنائية في المواد 22 و23، وأكدت عليها المادة 551 الفقرة الأولى والثانية من تقنين العدالة الإدارية، وتسمى بدعوى لاستعجال ما قبل التعاقد (le référé précontractuel) ⁴¹⁵، وهي صور خاصة للاستعجال وتمتيزة لما يملكه القاضي فيها من سلطة الأمر، والوقف، والإلغاء⁴¹⁶، فالقاضي المرفوع أمامه الطلب يجد نفسه مزود بسلطة النطق بتدابير مثلما يفعله قاض الموضوع، مع ميزة الفصل في أسرع الأجل طبقا لإجراءات خصوصية⁴¹⁷.

حيث تسمح النصوص التي نظمت هذه الدعوى لرئيس المحكمة بأن يوجه أمرا للإدارة بمراعاة التزاماتها المفروضة عليها قانونا في مجالي العلانية والمنافسة في إبرام عقود الشراء العام أو عقود تفويض المرفق العام⁴¹⁸.

وقد كرس القضاء مفهوما موضوعيا بما يجب فهمه من عدم مراعاة التزامات الإشهار والمنافسة، إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عما إذا انشغل الشخص العمومي بالتهرب من التزاماته بل بمعاينة أن تنظيم المنافسة لم يتم على ما يرام⁴¹⁹.

ويعتبر القضاء من قبيل مخالفة قواعد العلانية عدم مراعاة نشر الإعلانات لدى الجهات المحددة، أو خرق القواعد المتعلقة بمدد استلام العروض، كما يعتبر خرقا لقواعد المنافسة عدم احترام الإدارة للشروط المنصوص عليها في وثائق العقد⁴²⁰، وبموجب النصوص الناظمة لهذه الصورة من الاستعجال يملك القاضي سلطة الرقابة في القضاء الكامل ففي سبيل البحث عن مدى احترام الإدارة المتعاقدة التزاماتها بشأن العقد أو الصفقة يبحث في الأسباب التي دفعت إلى إقصاء الشخص من الحصول على الصفقة وإرسالها عليه⁴²¹.

ويكاد يكون المشرع المصري قد اقتبس هذه الصورة على النحو الموجود في فرنسا، حيث لتحقيق الفاعلية لأوامره نصت الفقرة الخامسة من المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على منح القاضي سلطة النطق بالغرامة التهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل الذي حدده

414-بازجي سلوى << رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري>>، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، السنة الثالثة، المجلد الخامس، العدد 01، 2012، ص 31.

415-ACH (N) << le référé précontractuel une réforme inachevée >>, A.J.D.A. n°23, 16 Décembre 2002, p. 1422. – CHAPUS (R), Op. Cit. p. 1439.

416-CHABANOL (D), Op. Cit. p. 195.

417- أنظر: لحسين بن شيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال، المرجع السابق، ص 261.

418-حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 189. - CHAPUS (R), Op. Cit. p. 1439.

419-لحسين بن شيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء الاستعجال، المرجع السابق، ص 189.

420-حمدي علي عمر، المرجع السابق، ص 189.

421-CHAPUS (R), Op. Cit. p. 1444.

القاضي للمتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته إذ جاء فيها <<ويمكن لها الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد ، ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها أن تأمر بتأجيل العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين يوما>>.

وهو ما أكد عليه المشرع الفرنسي في المادة 551 من تقنين العدالة الإدارية ، والقاضي لا ينطق بأي إجراء نهائي وفي المقابل يمكنه النطق بغرامة تهديدية حسب ما جاء في هذا النص تسري في أجل محدد من أجل دفع الشخص المعنوي العام لاحترام تلك الالتزامات ، وهذا التحديد يفسر من أجل ضرورة حفظ استمرارية المرافق العامة ومن جهة أخرى حتى لا يشل القاضي عمل الهيئات العامة في هذا المجال 422، وتوقيف أو تأجيل التوقيع على العقد لا يجوز أن يتجاوز المدة المحددة وهي عشرون يوما وإلا عد ذلك خطأ في تطبيق القانون 423.

Ach (N),Op .Cit. p. 1422.-422

C.E. 03 février 2010 , n° 330237 , communauté de communes de l'Arc mosellain , code -423
pratique ,Op .Cit . 1123.